

0001181-69.2017.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER, maior de 18 e menor de 21 anos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001181-69.2017.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001181-69.2017.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER, maior de 18 e menor de 21 anos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 329, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (fls. 01/02), eis que, supostamente, no dia 17 de maio de 2017, em torno da 16h40min, na Rua Irlanda, na via pública, Rochdalle, nesta cidade e Comarca de Osasco, trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e

regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em 35 (trinta e cinco) invólucros plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, no total de 19g (dezenove gramas) e 17 (dezessete) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L (maconha), no total de 23,40g (vinte e três gramas e quarenta centigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 08/09, laudo de constatação de fls. 10/12 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

2. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no mesmo dia, hora e local, GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER, maior de 18 e menor de 21 anos, qualificado a fls. 18, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, qual seja, os policiais civis Paulo Correia Coelho Filho e Fúlvio Damiani Manrique da Silva.

Segundo se apurou, policiais civis diligenciaram ao sítio dos fatos, oportunidade em que avistaram o denunciado em conduta suspeita, posto estar parado em uma viela, com uma sacola em mãos, além de ter demonstrado nervosismo ante à aproximação policial. Os policiais abordaram-no e, em revista pessoal, lograram encontrar, no interior da sacola que ele levava em mãos, as drogas apreendidas, e, no bolso de sua roupa, a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais), em dinheiro, em notas trocadas, fruto da mercancia espúria de drogas. Questionado, o denunciado confessou, informalmente, que ali comercializava entorpecentes.

Ao ser dada voz de prisão, no entanto, o denunciado resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e conduzi-lo à delegacia.

Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade e variedade de entorpecentes e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, dentre as quais a confissão informal, a presença de quantia em dinheiro de origem não revelada e a resistência, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04.

Laudo de constatação às fls. 12/14 e 62/64.

A denúncia foi oferecida às fls. 39/40.

Termo de audiência de custódia às fls. 66/69, na qual foi concedido ao denunciado o benefício da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares. Decisão de fls. 70/74 que confirmou a concessão do benefício da liberdade provisória ao acusado.

Alvará de soltura cumprido às fls. 75/76.

Laudo pericial às fls. 90/92.

Folha de antecedentes em nome do acusado às fls. 135.

Notificado às fls. 150, o acusado apresentou defesa prévia às fls. 165/170 por intermédio de advogado constituído às fls. 148/149. Protestou-se pela improcedência da acusação e foi requerida a notificação e oitiva da testemunha ocular arrolada.

A denúncia foi oferecida às fls. 181 no dia 14 de março de 2018.

Laudo de exame químico-toxicológico às fls. 183/187.

Às fls. 192 foi determinada a incineração da droga apreendida nos autos.

Às fls. 203 foi ouvida a testemunha PAULO CORREA COELHO FILHO.
Às fls. 204 o acusado foi interrogado.

Às fls. 205 foi ouvida a testemunha FULVIO DAMIANI MANRIQUE DA SILVA,

Às fls. 207 foi ouvida a testemunha SUELI APARECIDA ROSA RIALTO.

O Ministério Público apresentou memorial às fls. 214/218. Nesta oportunidade, requereu a procedência parcial da ação, absolvendo GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER do crime de resistência (artigo 329 do Código Penal) e condenando GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER pelo delito de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

A Defensoria Pública apresentou alegações finais às fls. 233/244 na qual pugnou pela absolvição do réu e, em caso de condenação, requereu que a pena fosse fixada considerando que o réu cometeu o delito com menos de 21 anos e é primário, tratando-se de um caso isolado.

É o relatório.

Fundamento

I - Em que pese o princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, §2º do Código de Processo Penal, anoto que o juiz que findou a instrução se removeu da 4ª Vara Criminal de Osasco. Sendo assim, mesmo não tendo colhido a prova, passo a proferir sentença valorando objetivamente e segundo os marcos legais, a prova produzida.

II - Quanto ao mérito:

O pedido é improcedente

II.1 Inicialmente, cumpre salientar que a legalidade da prova se confunde com o próprio mérito da demanda. Assim, tanto o espectro da legalidade quanto da existência de provas suficientes para uma reconstrução histórico-fática para além de qualquer dúvida serão analisados conjuntamente.

II.2 - Ainda de forma preambular, é de rigor anotar que as provas produzidas em juízo não trazem uma segurança cognitiva, objetivo-valorativa, para eventual decreto de condenação e isto porque se percebe que a produção da prova foi toda ela orientada e coordenada pelo Magistrado, o qual, de fato, fora o protagonista da fase instrutória. Verifico que as informações, logo as respostas na sequência, foram introduzidas no depoimento dos policiais para que estes pudessem confirmar o contido no auto de prisão em flagrante. E tanto o Magistrado fora o protagonista da instrução probatória que não houve qualquer repergunta pela acusação. Assim, não sendo observada, minimamente, a ritualística do art. 212 do CPP e, ainda, vergastado o devido processo legal na dimensão da necessidade da observância do processo acusatório, faltam garantias epistêmicas mínimas para a valoração racional objetiva por parte deste Juízo. Nesse sentido: STF - HC n. 187.035/SP - Rel. Min. Marco Aurélio - 1ª T - j. 06.04.2021).

Mas, mesmo se assim não fosse, as provas, nestes moldes produzidas, são insuficientes para um juízo de mérito que supere o postulado da presunção de inocência uma vez que, consoante narrados pelos policiais, em primeiro lugar, não havia razão suficiente para a abordagem do réu e, em segundo lugar, toda diligência foi orientada por "informações privilegiadas".

III.3 - Consto que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se

aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória não é suficiente a justificar a responsabilidade penal do réu. Não logrou o Ministério Público superar a presunção constitucional para além de qualquer dúvida objetivamente razoável, sendo os postulados da legalidade, conforme passo a expor. Em que pese a materialidade esteja demonstrada nos autos por meio do laudo químico toxicológico (fls. 183/187), a imputação de autoria não está suficientemente demonstrada nos autos.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147). Cumpre pontuar, nesse prisma, que o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente.

Uma das regras legais de valoração racional da prova vem insculpida no art. 155 do CPP. Este comando legal, a seu turno, estabelece limites ao livre convencimento objetivo do juiz, na medida em que dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos indiciários, colhidos em sede inquisitorial. É preciso que, quanto às provas orais, sejam elas avaliadas em contraditório judicial, com a observância da sistemática processual. A sentença, portanto, é fundamentada no fato de que: a) a prova colhida por outro Magistrado, em desrespeito às regras legais, não apresenta segurança necessária para qualquer juízo valorativo; b) mesmo considerando a versão dos policiais, a atuação está fundamentada em “denúncia privilegiada” e não havia razão para a abordagem do réu, o que contamina todo restante da prova.

No caso dos autos, as provas são eminentemente orais e não houve a produção de prova – sujeita ao crivo do contraditório, dentro dos marcos da legalidade – que permita a demonstração, para além de qualquer dúvida racional-objetiva, das premissas fáticas da acusação.

O réu, interrogado em juízo, negou a propriedade das drogas.

Em primeiro lugar, todo o desenrolar fático, segundo afirmam as testemunhas, teve origem em “denúncia privilegiada”. Não obstante não haja qualquer registro na persecução penal, o que, por si só, coloca em xeque a abordagem do acusado, os policiais, ainda, não esclareceram quaisquer características constantes da notícia apócrifa que os levaram ao local dos fatos e que justificasse a abordagem do réu. Em segundo lugar, os policiais informam que a droga estaria em uma sacola e que a sacola teria sido encontrada com o réu. O réu, por sua vez, nega tal fato. A verdade é que, pelo que se percebe, não havia razão jurídico-fática para abordagem do réu, o que inquina a prova de ilegalidade pois os policiais afirmaram que chegaram ao local após “denúncia privilegiada” e teriam abordado o réu que estava no local. O réu, sobre estar no local, aduz que teria ido para comprar droga e

estava esperando o vendedor chegar.

Portanto, o que se tem é que a busca pessoal do acusado derivou tão-somente de “denúncia anônima” ou “privilegiada” como se extrai dos autos, o que invalida a prova. E mais, não há outros elementos que apontem que, de fato, a sacola estivesse na posse do réu ou, mesmo que encontrada próximo, haveria vínculo fático de propriedade/posse com o réu.

Nesse sentido: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 734263 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2022/0100276-4 - REL. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148) - ÓRGÃO JULGADOR - T6 - SEXTA TURMA - DATA DO JULGAMENTO 14/06/2022 - DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE - DJe 20/06/2022

Destarte, tendo como base uma colheita de prova baseada em ato inquisitivo do magistrado, somando a ausência de certeza de legalidade quanto a prova, não é possível a formação de qualquer juízo cognitivo de condenação baseado em preceitos democráticos de respeito aos cânones legais-constitucionais.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório, com a observância das leis. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Quanto ao crime de receptação a absolvição se impõe não apenas porque houve pedido do Ministério Público, mas pelas mesmas razões, em especial pela dúvida quanto a qualidade do ato dos policiais, eis que o tipo penal exige que a aposição seja a “ato legal”.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal e ABSOLVO o acusado GABRIEL DE OLIVEIRA XAVIER, maior de 18 e menor de 21 anos da acusação de ter infringido o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 329 “caput” do Código Penal, com fundamento no art. 386. Inc. VII do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Osasco, 22 de agosto de 2022.